

1502299-48.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... policiais que estivesse praticando o tráfico de drogas. Disse que é padrinho do filho de Bruno, que é seu amigo e é padrinho do filho dele e sabia que Bruno realizava o tráfico de drogas, porém não o entregou aos policiais e não indicou onde era sua residência. Disse que não viu os policiais abordando Bruno, mas soube que os policiais o liberaram porque Bruno o indicou como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502299-48.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502299-48.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVAN PORFÍRIO CORDEIRO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

EDIVAN PORFÍRIO CORDEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado (já computado o aditamento de fls. 178/179 para correção do erro material quanto ao local e à data dos fatos) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 15 porções de maconha, 52 porções de crack e 57 porções de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica. Foi, ainda, apreendida com o acusado a quantia de R\$54,00.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do

acusado nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando falta de provas.

Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o afastamento da circunstância agravante quanto ao período de calamidade pública.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, pela prova oral colhida, bem como pelo restante do conjunto probatório constante dos autos.

Da mesma forma, não restam dúvidas quanto à autoria do crime.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Disse que havia saído de sua casa e passou de bicicleta pelo local dos fatos, onde parou para conversar com um indivíduo de nome Bruno, que o chamou para consumirem maconha. Contou que ficou alguns minutos com esse indivíduo usando a droga e depois atravessou o canal, parou em frente ao salão de Fernando e, então, conversou com um indivíduo de nome Alex, que estava arrumando um veículo. Alegou que, nesse momento, policiais aproximaram-se e o abordaram, dizendo que nada tentasse, pois seu parceiro o havia delatado e indicado que a droga estava na Kombi. Alegou que, após, um terceiro homem, que não foram os policiais depoente, aproximou-se com uma sacola na mão, dizendo que havia encontrado as drogas. Contou que negou aos policiais que estivesse praticando o tráfico de drogas. Disse que é padrinho do filho de Bruno, que é seu amigo e é padrinho do filho dele e sabia que Bruno realizava o tráfico de drogas, porém não o entregou aos policiais e não indicou onde era sua residência.

Disse que não viu os policiais abordando Bruno, mas soube que os policiais o liberaram porque Bruno o indicou como sendo o autor do crime. Contou ser usuário de maconha. Disse que somente Alex presenciou sua abordagem, mas não Fernando, pois este estava dentro do salão.

Entretanto, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se a realização do tráfico de drogas por ele. Além disso, sua versão apresentada em Juízo, além de não ser crível, não encontra respaldo no restante das provas produzidas durante o processo.

A testemunha policial civil Bruno Tadeu de Brito Alves, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, na data dos fatos, em razão de notícia recebida acerca da ocorrência de tráfico de drogas, diligenciou no local indicado, onde permaneceu parado em viatura descaracterizada. Narrou que visualizou o acusado ao lado oposto do canal, conversando com outro indivíduo. Declarou que viu pessoas aproximando-se do réu para adquirir drogas, viu que tais pessoas conversavam com o acusado e viu que, enquanto tais pessoas permaneciam no mesmo local, o acusado, então, atravessava o canal, dirigindo-se até um veículo que parecia estar abandonado, onde, aparentemente, pegava entorpecentes e com eles retornava até as pessoas que o aguardavam. Afirmou que viu a movimentação característica da venda de drogas por cerca de três vezes. Relatou que, feita a abordagem, com o acusado somente foi encontrado dinheiro. Consignou que as drogas apreendidas eram das espécies maconha, crack e cocaína e estavam próximas ao pneu do veículo mencionado, mas não recordou de que forma elas estavam acondicionadas. Disse que, informalmente, o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas no local há pouco tempo. Esclareceu que a notícia recebida indicava o local dos fatos e mencionava que o indivíduo que realizava o tráfico estava de bicicleta, mas não informava características físicas. Relatou que a campana teve duração entre 20 e 30 minutos e foi realizada a uma distância próxima, de cerca de 30 metros do local onde estava o acusado, asseverando que, do local de onde o monitoramento foi feito, podia visualizar tanto o réu quanto o veículo onde ele buscava as drogas, estando cada um em uma margem do canal. Declarou que o indivíduo com quem viu o réu conversar inicialmente foi embora do local e não foi mais visto. Disse que nenhum usuário de drogas foi abordado. Consignou que constatou que o acusado havia buscado drogas no veículo após a abordagem e a busca realizada, porém visualizou o réu realizando a conduta

típica do tráfico de drogas em uma região onde já possuía conhecimento da ocorrência deste delito. Declarou que moradores observaram a abordagem, mas não se aproximaram. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. No mesmo sentido, a testemunha policial civil Fábio da Costa, ouvida em Juízo, narrou que, recebida notícia versando sobre o tráfico de drogas em local já conhecido pela ocorrência deste crime, dirigiu-se ao local indicado para averiguar a informação e, lá chegando, em viatura descaracterizada, passou pelo acusado e o viu na companhia de outro indivíduo, sem que ambos tivessem notado a presença da equipe policial. Relatou que posicionou a viatura na margem oposta à que o réu e o outro indivíduo estavam, e lá permaneceu realizando o monitoramento por 30 a 40 minutos. Afirmou que, durante o monitoramento, viu indivíduo aproximando-se do réu, com ele conversando, e viu o acusado dirigindo-se até o veículo de marca Kombi, aparentemente abandonado, pegando algo sob os pneus, retornando para entregar algo ao indivíduo que o aguardava, recebendo algo em troca. Asseverou que viu essa mesma movimentação ocorrer por duas a três vezes. Relatou que, feita a abordagem, o acusado admitiu, informalmente, que estava praticando a traficância, mas não indicou o local onde estavam as drogas. Disse que, em busca no local onde estava a Kombi, foi localizada, sob o pneu traseiro, uma sacola plástica contendo cerca de 115 porções de maconha, crack e cocaína. Relatou que, na posse do réu, foi apreendida a quantia de R\$54,00, mas não foram encontradas drogas. Consignou que, diante da hostilidade contra a equipe policial, saíram do local rapidamente, mas recordou-se que ali foi dada a uma pessoa ciência sobre a prisão do acusado. Narrou que o monitoramento foi realizado a uma distância aproximada de 35 a 40 metros do local onde estava acusado, não muito distante, consignando que a viatura estava estacionada em um lado da margem do canal, oposta àquela em que estava o acusado. Esclareceu que o acusado, ao ser procurado pelos indivíduos, atravessava uma ponte próxima de bicicleta, para buscar a droga no veículo estacionado e, então, retornava. Declarou que já realizou apreensão de drogas na mesma avenida, mas em local diverso daquele em que o réu foi abordado. Disse que nenhum usuário de drogas foi abordado, o que despertaria a atenção do acusado. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais que, de maneira segura, uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do réu e a localização e apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se “imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento” (TJSP – AP – Rel. Walter Guilherme – j. 10.03.98 – JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se

favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2 T.- HC n. 74.522-9/AC - Rel. Min. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.
5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.
6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.
7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por

gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais civis não é suficiente para retirar a força probante deles.

As testemunhas puderam relatar detalhadamente de que forma ocorreu e o que motivou a abordagem do acusado.

De forma pormenorizada, narraram as testemunhas que viram o réu ser procurado, por mais de uma vez, por indivíduos que com ele conversavam, vendo que o acusado atravessava sozinho a ponte para a margem oposta do canal, dirigindo-se a um veículo aparentemente abandonado, para ali buscar algo que, então, entregava aos indivíduos que o aguardavam, perfazendo uma conduta típica de venda de entorpecentes.

Relataram que, feita a abordagem, com o réu somente foi encontrado dinheiro, mas, em busca no local onde o viram mexer, localizaram os entorpecentes variados que foram, então, apreendidos.

Consignaram as testemunhas que a campana foi realizada por tempo aproximado de meia hora e a uma distância que possibilitava ver toda a ação criminoso.

Declararam que nenhum dos indivíduos que manteve contato com o acusado foi abordado e acrescentou a testemunha policial Fábio que tal abordagem não se mostrava possível, sem que a atenção do acusado para a presença da equipe policial fosse despertada.

Frise-se que os depoimentos dos policiais, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização do entorpecente, estando em verdadeira harmonia com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Depreende-se da narrativa das testemunhas policiais civis não haver qualquer dúvida, portanto, de que o réu era a pessoa que estava realizando o tráfico de drogas, bem como que a ele pertenciam as porções de drogas apreendidas no mesmo local manuseado por ele.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado, além de não se mostrar crível, restou absolutamente isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado – de que somente permaneceu junto ao verdadeiro do traficante por pouco tempo a fim de com ele consumir drogas e que os policiais teriam deixado de deter o verdadeiro meliante, que era seu amigo, porque este o apontou falsamente como autor do crime – sobreponha-se ao depoimento dos policiais que realizaram sua prisão em

flagrante e localizaram as drogas, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais - que sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos - e as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é, de fato, traficante.

Consigne-se que não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas. Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da quantidade, natureza e variedade de drogas encontradas, e das demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - AC 1.327/92 - Rel. Adolphino A. Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu em relação a esse delito é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena. Assim, fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 1/6, ficando ela estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesmo delito, conforme certidão criminal de fls. 128, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estabelecido.

Sobre o aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às

condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento a serem reconhecidas e não é possível reconhecer-se a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade de drogas apreendidas, bem como diante da reincidência específica do acusado.

Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Da mesma forma, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa.

Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte

público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII - Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Ressalte-se, outrossim, que o acusado é reincidente em razão da prática do crime de tráfico de drogas, conforme já exposto, elemento que somado à quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, observada a reincidência do acusado, e cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e

recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDIVAN PORFÍRIO CORDEIRO, qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, além de ser o acusado reincidente específico. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Destaca-se, ainda, a quantidade, a natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos com o acusado, o que, como também já ressaltado, demonstra que não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 18 de agosto de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA